

CÁMARA DE ACUSACIÓN DE CÓRDOBA
Resua, Ernesto E. • 22/09/2000

Córdoba, setiembre 22 de 2000.

Considerando:

1) a) que a fs. 114 comparece el doctor D.C.C., defensor del imputado Ernesto E. Resua expresando que viene por el presente a interponer recurso de apelación en contra de la ya citada resolución, fijando como puntos de agravio: "...a) Con los elementos probatorios arrojados al proceso no ha quedado acreditada debidamente la participación del mi (su) defendido en el evento que se investiga, ni siquiera con el grado de presunción requerido en esta etapa del juicio. b) Que en el caso investigado no es delito, resulta atípico en razón de que en el caso de acreditarse su acontecer sólo se trata de maniobras preparatorias y no de un principio de ejecución y mucho menos su consumación. c) No hizo lugar al planteo de nulidad deducido en contra de las conclusiones de perito actuante, no obstante haberse conculcado el ejercicio del derecho de defensa en juicio...". Concedido el recurso de que se trata y elevados los presentes autos por ante este Tribunal ha vencido el término que establece el art. 462 del CPP., habiendo informado en término el apelante, haciéndolo por medio de escrito fundado que obra a fs. 117/120, de todo lo que da cuenta el certificado del actuario que luce a fs. 121.

2) Que el hecho que habría dado motivo a las presentes actuaciones habría acaecido de la siguiente manera: "...No pudiéndose precisar con exactitud el día ni la hora como tampoco el año, pero en un período comprendido entre 1998 y el 12 de noviembre de 1999, en ..., de esta ciudad de Córdoba, el prevenido Ernesto E. Resua, reprodujo seiscientos cinco (605) Compac Disc (o Discos Compactos), con el fin de lucro y sin la autorización escrita de su productor o del licenciado del productor. El día doce de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, siendo las once horas aproximadamente, se realizó un allanamiento en el domicilio anteriormente citado del prevenido Resua, donde se logró el secuestro de aproximadamente 623 Compac Disc, de los cuales 605 de ellos resultaron ser apócrifos y dentro de estos últimos, 73 correspondían a música y los restantes -522- a programas para PC. Además se secuestraron carátulas scaneadas para ser aplicadas a CD y una computadora completa; un C.P.U., marca Simecom, sin numeración visible, con sus compacteras y grabadora, una impresora marca Cannon modelo BJC-7000, n° de serie EXDS 7740, un Scanner marca "Primax" 6009 modelo FB31 ED, n° de serie 906A014934D1, un monitor de Computadora marca "Kelly" modelo 5D144K, n° de serie 8716007152, todas las partes anteriormente nombradas estaban unidas entre sí y la misma en forma completa, destinada a cometer el ilícito..." (Conf. fs. 105/105 vtas.,).

3) Que al ser llamado a los fines de prestar declaración en sede judicial el prevenido Ernesto Resua Lian (fs. 57) manifiesta su deseo de abstenerse de declarar. IV. Que al fundamentar su resolución, el juez de control n° 2 luego de señalar que la investigación en la presente causa se inicia con la denuncia formulada por el doctor G.C. (fs. 1/4) como apoderado de BMG Arriola Argentina S.A.; EMI ODEON S.A.C.I.C.; Podygramn Discos S.A.; Sony Music Entertainment (Argentina S.A.); Universal Music S.A. y Warner Música Argentina S.A. (Conf. poder de fs. 5/23), dando a conocer que en distintos lugares de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales se encontraban adheridos pequeños anuncios que rezaban se copian CD's -Solicitar catálogos -Música & PC- a sólo \$12, = Tel. ... que como primera medida se recabó al Director de Telecom

Personal acerca de la titularidad de la línea telefónica aludida, el cual le respondió que esa línea pertenecía a Ernesto Lian Resua, con domicilio en Que el día 12 de noviembre de 1999 se practicó un allanamiento a dicho domicilio, siendo el mismo "positivo" ya que se secuestraron efectos relacionados con la investigación. Que con dichos elementos, el Personal de Policía Judicial -Gabinete de Audio y Video Legal- examina los mismos y luego realiza el informe a fs. 48/55 vta., en donde especifica que de los seiscientos veintitrés (623) Discos Compactos, quinientos veintidós (522) de ellos son "Apócrifos". Que también el mencionado informe detalla en un anexo fotográfico una comparación entre un C.D. original y uno apócrifo. Que de la misma manera se procedió con las carátulas escaneadas. Que a los fines de una mayor ilustración se recetó la declaración testimonial de Néstor O. Hinzmann (fs. 56) quien trabaja en la Oficina de Audio y Video Legal de la Policía Judicial, el cual expresa que al realizar el referido informe le fue materialmente imposible especificar el contenido de cada uno de los discos compactos, ya que se carece de recursos para ello. Que lo único que se pudo establecer fue diferenciar los que corresponden a música de los que atañen a programas de computación para PC. También se destaca el Informe Técnico realizado por la Oficina de Investigación y Desarrollo de Sistemas de la Policía Judicial de fs. 80/82 vta., relacionado con la operatividad de la computadora secuestrada y si la misma era apta para realizar copias en CD recordables. Al respecto ha depuesto el Ingeniero Arsenio A. Cardone (fs. 86) quien suscribe el informe citado, el cual relata que la referida computadora posee instalada y operativa, la "grabadora de Discos Compactos" y, a la vez, se encuentran instalados los programas o Software, que permiten realizar grabaciones sobre discos compactos en ella. Que esta computadora actualmente posee una tecnología bastante avanzada. Por último destaca el juez de Control que ha pedido de la defensa se ordenó una Pericia Caligráfica de las carátulas de fs. 62/62 vta. y que la mencionada pericia (fs. 75/77 vta.) concluyó que en la escritura de los manuscritos cuestionados, no habría intervenido el puño escrito del encartado, lo cual no es óbice -dice- para no tener por acreditado el hecho que se le enrostra al prevenido Ernesto Lian Resua, ni su participación en el mismo. Sostiene, en consecuencia, que el imputado Resua montó todo un operativo, con una habitualidad de los hechos, que no pueden ser considerados como aislados o limitados a la utilización doméstica de las copias. Que esta modalidad expuesta "la llamada Piratería Musical" causa un gravísimo perjuicio, tanto a autores, compositores e intérpretes, y se encuentra protegida en el art. 17 de la Constitución Nacional, de la misma forma que lo hacen los Convenios y Convenciones Internacionales (ley 19.963 y la ley 23.921, tomo 1961 y Ginebra 1987). Que esta conducta del prevenido Resua es violatoria de los Derechos de Propiedad Intelectual, reconocidos y amparados por la ley 11.723. Que con relación a la solicitud de declaración de nulidad absoluta de la pericia, cuyo informe corre glosado en autos a fs. 48/49 vta., y de todos los actos relacionados y concatenados a ella, el juez de Control al no compartir esa postura ha expresado que el hecho de que una operación técnica se la practique como informe técnico en vez de pericia, no invalida el primero, el cual será valorado conforme a las reglas de la sana crítica racional y a las posibilidades de refutación y posterior control que pueda tener la defensa en el caso concreto. Que habida cuenta que el representante del ministerio público está facultado para basar sus requerimientos en los actos de la Policía Judicial y que el defensor puede hacer valere los derechos inherentes al contradictorio en la etapa del juicio, se torna más que evidente aún la validez del acto cuestionado. Que no empece a esta conclusión el hecho que se hayan abierto las cajas donde se hallaban los discos compactos secuestrados, toda vez que no se advierte riesgo para la individualización del secuestro, en razón de que está el acta que describe el mismo y las fotografías, todo bajo custodia judicial.

4) El estudio de la totalidad de las probanzas incorporadas al presente no determinan en afirmar lo siguiente: a) En lo que hace a la solicitud de declaración de nulidad del informe obrante a fs. 48/49 vta. producido por el Departamento de Audio y Video Legal de la Policía Judicial de la Provincia de Córdoba intentada por la defensa del prevenido Ernesto E. Resua "...en razón de haberse omitido la notificación de su realización a esta parte y con lo que se ha violado el derecho de defensa en juicio al impedir su Control..." (ver fs. 102 supra), entendemos que no le asiste razón al apelante. En efecto, ya de antiguo este Tribunal tuvo ocasión de expedirse en tema relacionado como el presente. Así, en "in re" "Jáuregui Guillermo A. -homicidio culposo", Auto n° 181, del 18/11/92, Sec. 2 "esta Cámara expresó. "...los informes técnicos atacados no revisten para nada, como lo pretende la defensa, el carácter de prueba pericial, sino que solamente son eso: informes técnicos...". que al respecto, el doctor José I. Cafferata Nores, en su obra "La Prueba en el Proceso Penal", Ed. DePalma, año 1986, p. 195 ha expresado que el CPP no se ocupa sistemáticamente de esta prueba, no obstante, el hecho de tratarla, esto permite considerarla como comprendida entre todas las diligencias conducentes al descubrimiento de la verdad... y sostener la legitimidad de su utilización para otros casos no previstos especialmente... habrá que tener especialmente, al momento de evaluar la idoneidad probatoria del "informe" las posibilidades que ofrezca para su directa verificación en los registros respectivos por las partes y el Tribunal...". Al respecto consideramos que teniendo siempre en cuenta lo que expresa el art. 41 de la Constitución de nuestra Provincia "...los actos que vulneran garantías establecidas...", en nuestro Código Procesal Penal se atribuye a la Policía Judicial (CPP. art. 324, inc. 3°) "...hacer constar el estado de las personas, cosas y lugares... mediante ... exámenes técnicos y demás operaciones que aconseje la policía científica...". De lo expresado precedentemente podemos decir que el "informe técnico" excluye por completo la emisión de un juicio, teniendo el acto por finalidad sólo el de "hacer constar el estado de las personas, cosas y lugares". Por el contrario, la "Pericia", en cambio, debe ser ordenada por un órgano judicial, con observancia de todas las disposiciones tendientes a garantizar la seriedad de las conclusiones periciales del Ministerio Fiscal y las partes, la cual será llevada a cabo por un experto titulado. Al respecto, nos parece conveniente citar al doctor Vélez Mariconde quien en su Exposición de Motivos para la reforma del año 1970 y con relación a los planteos sobre la validez de los "informes técnicos" se expresaba diciendo que "...no se puede impedir el ingreso de esos elementos técnicos recogidos en el primer momento de la investigación que podrían ser valiosos, so color de que no han sido controlados por el defensor...". Debe, pues, desestimarse la solicitud de declaración de nulidad del informe del Departamento de Audio y Video Legal de la Policía Judicial de fs. 48/49 vta.

b. Oposición deducida en contra de la requisitoria fiscal de elevación a juicio: 1. Tratamos en el caso de una norma penal complementaria contenida en la ley 11.723, debiendo ser analizada y aplicada conforme las pautas del art. 4 del CP. La conducta reprochable penalmente, entonces debe ser típica, antijurídica, culpable y punible. 2. El art. 1° de la ley 11.723, establece "A los efectos de la presente ley, las obras científicas, literarias y artísticas comprenden los escritos de toda naturaleza y extensión, entre ellos los programas de computación fuente y objeto; ... composiciones musicales... los impresos..., sea cual fuere el procedimiento de reproducción. La protección del derecho de autor abarcará la expresión de ideas, procedimientos, método de operación y conceptos matemáticos pero no esas ideas, procedimiento, métodos y conceptos en sí." Por su parte el art. 4°, de la ley citada establece quienes son los titulares de los derechos de propiedad intelectual. El procedimiento para la Registración de Obras, se regula a lo largo de los arts. 57 a 64; siendo destacable, a los efectos de la resolución del presente

recurso, lo dispuesto en el art. 61 en relación a la obligación del depósito de toda obra publicada para el editor de la misma; lo que garantiza totalmente los derechos del autor de su obra y los del editor sobre su edición. Por su parte el art. 63 taxativamente nos dice que: "La falta de inscripción trae como consecuencia la suspensión del derecho del autor hasta el momento en que la efectúe, recuperándose dichos derechos en el acto mismo de la inscripción...". Ello es congruente con la idea de la doctrina: "2. Folio Real: El punto de referencia es la obra. Es ella por su título que ingresa como objeto registrable, ...pero siempre debe haber por lo menos un ejemplar que materializa la creación literaria o artística para que el registro proceda. Desde la obra se obtienen los demás elementos que constituyen el acopio de datos: autor, editor, productor, traductor, cesionario, medidas precautorias, etc. En general todos los registros de obras intelectuales siguen el método que podemos denominar del 'Folio Real', aún cuando las leyes o reglamentaciones no lo establezcan en forma expresa (Argentina, Uruguay, Chile, México, entre otros). ..." (Retondo Hilda, "Vº Congreso Internacional sobre la protección de los Derechos Intelectuales -del autor, el artista y el productor-", Compañía Impresora S.A. 1990, p. 119/120).

3. De lo expuesto supra es dable deducir que para que el derecho de autor sea protegido, conforme el sistema adoptado por la ley 11.723, se necesita de la previa registración ante la Oficina respectiva, que incluye el depósito de la obra u obras que el autor ha creado (art. 57, ley 11.723). Ello sin perjuicio que según lo reconocido por la doctrina y Jurisprudencia, en sí mismo la creación original de una obra, otorga incuestionables derechos morales a su autor por el simple hecho de la creación. No podría ser de otra manera. No obstante, en el ámbito del Derecho Penal, a la par de ese derecho reconocido -nos referimos al caso de las obras registradas- se deben cuidar además otros elementos que hacen a los derechos de aquellas personas -como en el caso de autos- a quienes se les atribuye un actuar ilegal. En este orden de ideas, inexorablemente debe demostrarse que cada obra reproducida probablemente en forma ilegal, es objeto de la protección legal. De autos no surge tan siquiera un listado de las obras que se achaca haber reproducido ilegalmente. Es más: en la relación del hecho intimado al acusado (ver fs. ...) se expresa que Ernesto Lian Resua "...habría reproducido un sinnúmero de CD, con fines de lucro y sin la autorización expresa de su reproductor o del licenciado del productor...". Al relatar el hecho S.S. sin embargo, establece que "el prevenido Ernesto Lian Resua reprodujo seiscientos cinco (605) Compact Disc (o discos compactos), ...donde se logró el secuestro de aproximadamente 605 de ellos resultaron ser apócrifos y dentro de estos últimos, 73 correspondían a música y los restantes -522- a programas para PC. ...".

4. Debemos hacer algunas observaciones: a) en primer lugar, resulta evidente la incongruencia entre la intimación y el Auto de Elevación a Juicio con relación al relato de hecho. b) S.S. atribuye como conducta disvaliosa no poseer el imputado autorización escrita del productor o del licenciado del productor para los 605 compact disc, cuando la tipificación de "productor" se encuentra establecida sólo para los fonogramas (art. 72 inc. a, ley 11.723). c) No se identifica el contenido de cada disco compacto, con lo que es imposible determinar cuales son las obras registradas supuestamente copiadas en forma ilegal; y por ende el derecho de cuales autores ha sido vulnerado. d) Por otra parte, el juez de Control ha imputado a Resua la copia defraudatoria de programas de computación que, además de no haber sido identificados tampoco, tienen un régimen - en orden a determinar una conducta criminal- distinto al de los fonogramas.

Damos razones: El art. 72 bis de la ley 11.723 (agregado por ley 23.741) establece en el inc. a, como conducta delictiva especial el que "con fin de lucro reproduzca un fonograma sin autorización por escrito de su productor o del licenciado del productor",

con lo que queda expresado que la atribución a Resua de ilicitud en la reproducción de programas de computación, no constituye delito. Por otra parte, reiteramos, los discos compactos con sólo fonogramas, no han sido identificados debidamente, y no surge de la prueba obrante en autos si los autores habrían registrado debidamente sus obras y quienes resultan perjudicados patrimonialmente por las maniobras supuestamente defraudatorias, requisito éste al que se remite el art. 71 de la ley citada.

5. En consecuencia de lo manifestado, advertimos que el imputado no ha podido defenderse adecuadamente. Ello, sin perjuicio de repudiar la conducta de quienes se aprovechan de la creación artística de terceros, para obtener un lucro indebido. El avance tecnológico y el fácil acceso a herramientas que permiten la reproducción ilimitada e indiscriminada de fonogramas, programas para computadoras, fotografías, cuadros, películas, etc., requiere una rápida adecuación de las técnicas y políticas de investigación y persecución de los delitos que se generan; pero no es admisible imputar a todo ciudadano que copia obras artísticas o científicas por el mero hecho de hacerlo, sin determinar -además del ánimo de lucro-, que la obra reproducida se encuentra protegida por la ley. Lo contrario significaría una sospecha permanente sobre cada persona que posea una computadora.

6. Cabe agregar, aún a riesgo de resultar repetitivos, que el régimen legal para la registración de fonogramas (obras musicales) y de programas de computación es distinto. En ambos casos, según lo establece el art. 57 (que remite al art. 1º ya reproducido por la ley 11.723) se requiere el depósito de tres ejemplares completos de la obra; pero para el caso de los softwares (programas de computación) el mismo art. citado establece que "consistirá en el depósito de los elementos y documentos que determine la reglamentación". Hasta el presente no se ha reglamentado dicho depósito.

7. En conclusión, no podemos determinar si se ha violado "el derecho de autor", toda vez que ignoramos quienes serían los autores y si los mismos tienen derecho a la protección legal que se invoca, por haber registrado previamente conforme a las formalidades de ley su obra. Cada disco compacto, sólo examinado en su exterioridad, se supone contiene la reproducción de múltiples temas musicales, de diversos autores; como así también, en otros, diversos softwares. Los mismos no han sido identificados debidamente, por lo que desconocemos si cada uno de los temas o programas informáticos tienen actualmente el amparo legal que brinda la ley 11.723. En definitiva, esta Cámara opina que para poder atribuir una conducta penalmente disvaliosa al incoado, se requiere la previa acreditación de que las obras pertenecen a alguien y que se han cumplido con los requisitos de inscripción necesarios, en razón de que la "propiedad intelectual" es un bien registrable. En el caso bajo examen, ni siquiera se ha identificado de qué obras se trata, por lo que mal puede achacarse una conducta penalmente reprochable. Solo sabemos de la existencia de poco más de 600 Compact Disc secuestrados. Si no se ha determinado qué obras están contenidas en cada disco compacto, y si ellas se encuentran debidamente registradas, entendemos que no se ha acreditado mínimamente la existencia de una conducta típica, antijurídica, culpable y punible, que amerite la realización de un juicio de debate.

8. A la resolución hoy apelada, se arriba por la oposición de la defensa a la requisitoria fiscal de elevación a juicio obrante a fs. 92. Dicha pieza, adolece también de la incongruencia al relacionar el hecho con el hecho intimado; por lo que es también achacable a la actuación fiscal los mismos motivos observados con respecto al Juez de Control, que suponen falta de precisión y especificidad, lo que la tornan inevitablemente nula. Ello, en razón que la acusación si bien clara y circunstanciada no ha sido precisa (toda vez que no ha puntualizado con exactitud si la acusación es con relación a todos los discos compactos secuestrados o solamente con respecto a música), ni específica (ya

que tampoco describe con esta característica la conducta reprochada penalmente a Resua y que amerita el pedido de citación a juicio), condiciones consagradas en el art. 355 CPP, bajo pena de nulidad. "Por otra parte, la fijación del hecho objeto de la acusación reviste primordial importancia y así hemos dicho: 'esa pieza acusatoria es base del plenario, sobre la cual versará la prueba, discusión y sentencia (arts. 382 in fine, 390, 402, 410 y conchs. del C.P.P.)'. Tal omisión, que impide que imputado y defensor conozcan exactamente los hechos que se le atribuyen y por los que va a ser juzgado, resultan violatorias del art. 186 2º párr. -"in fine"- de la ley adjetiva, y por ello una nulidad declarable de oficio.". (cfr. Balmaceda, Gustavo Sebastián", causa B-04-00, Secretaria 2).

Por todo ello y lo dispuesto en los arts. 355, 261, 355, 358, 282, 184, 185 inc. 3º y 196 del C.P.P., corresponde sin más declarar la nulidad de la intimación formulada al imputado Resua, de la Requisitoria Fiscal de Citación a Juicio y del Auto de Elevación a Juicio; sin costas (art. 551, C.P.P.). Por todo lo expuesto y normas legales citadas, el Tribunal

Resuelve:

Declarar la nulidad total y absoluta de la intimación formulada al imputado Ernesto Lian Resua, de la Requisitoria Fiscal de citación a Juicio y del Auto de Elevación a Juicio (arts. 261 2º párr., 355, 358 en función del 282, 184, 185 inc. 3º y 196 "in fine", C.P.P.); sin costas (art. 551 ibíd). –

Miguel A. Funes. -Raúl Mallia Bresoli. -Francisco H. Gilardoni.